

1501649-62.2020.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/02/2022

... quantidade, por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

Por fim, anoto que o fato de ter sido absolvido em um processo de roubo, como demonstrado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501649-62.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501649-62.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2288250/2020 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 14763357 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI,

3630/20/309 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2288250 - 01º D.P. BIRIGUI, 3630/20/309 -

01º D.P. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE ALVES MOREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1501649-62.2020.8.26.0603 (Controle 1311/19)

VISTOS.

ANDRÉ ALVES MOREIRA, vulgo "Kiko", qualificado nos autos, foi preso em flagrante

delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 02h23min, na Rua Doutor Artur Cordeiro, Vila Xavier, cidade e comarca de Birigui, guardava e tinha em depósito, 01 (um) eppendorf de cocaína, pesando 8,05 (oito gramas e cinco centigramas) gramas e 12 (doze) porções de maconha, pesando 47,62 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos periciais de fls. 20/21, 133/135 e 136/141.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa escrita (fl. 171), cuja peça foi juntada às fls. 167/168, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 09 de junho de 2021 (fls. 190/191) e a citação do acusado (fl. 212). Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 04 (quatro) testemunhas arroladas em comum e 01 (uma) testemunha arrolada pela defesa, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do réu (fls. 243/244).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 255/260).

A defesa, por sua vez, alegou, preliminarmente, nulidade do processo, porque ocorreu invasão de domicílio. Ademais, pediu a absolvição do réu, alegando que é usuário de drogas. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal, com aplicação do § 3º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, bem como o reconhecimento da menoridade relativa e da confissão. Pleiteou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com a fixação do regime aberto (fls. 264/271 e 272/273).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

A matéria arguida pela defesa, quanto à busca domiciliar na casa do acusado sem mandado judicial, fica rejeitada. Pelo que relatou na denúncia, os policiais militares abordaram um indivíduo que informou que trocaria um objeto por drogas na residência do réu, razão pela qual se dirigiram até a referida residência, no intuito de encontrarem as drogas, razão pela qual houve situação que ensejava o estado de flagrância, justificador da entrada dos policiais, logo em seguida, na residência do acusado, sendo dispensável qualquer ordem judicial.

Logo, evidente que houve situação que ensejava o estado de flagrância, justificador da entrada dos policiais, sendo dispensável qualquer ordem judicial. Ademais, embora a casa seja o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformada em garantia de impunidade de crimes que em seu interior se praticam. Assim, em se tratando de flagrante delito, não é necessário mandado de busca e apreensão domiciliar, pois o próprio texto constitucional admite que se penetre na casa mesmo à noite, e sem o consentimento do morador, no caso de flagrante delito, como foi o ora tratado.

Como se não bastasse, é cediço que, em se tratando de crime permanente, é dispensável qualquer exibição de mandado e a presença de civis no local, até porque se sabe que, no mundo do tráfico, é comum as testemunhas não aparecerem para depor e são raras as pessoas que prestam depoimentos em juízo, tudo por receio de represálias e ameaças por parte dos traficantes. Desprezar, como regra, a ação dos policiais em caso como o dos autos, seria fechar os olhos para a nossa realidade, o que seria inadmissível.

No mérito, a ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); o boletim de ocorrência (fls. 12/14); a nota de culpa (fl. 10); o relatório final (fl. 142); o laudo de constatação prévia (fls. 20/21); os laudos periciais (fls. 133/141); os depoimentos das testemunhas e as indigestas negativas apresentadas pelo acusado em

ambas as fases da persecução penal.

O réu, tanto na delegacia, quanto em juízo, negou a prática criminosa. Disse que dormia quando os policiais chegaram na sua casa e nada de ilícito foi localizado. Disse que é usuário, mas negou a propriedade da droga encontrada. Negou ter confessado aos policiais que estava vendendo drogas e a quantia apreendida não era sua também (fls. 09 e 243/244).

A negativa apresentada pelo acusado está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

As testemunhas Erlon de Souza Tavares e Zodir Prates de Oliveira Coirano, policiais militares, ouvidos em ambas as fases, relataram que estavam em patrulhamento quando abordaram uma pessoa que saía da residência do acusado e que disse que havia ido até lá para comprar drogas. Após, abordaram um indivíduo chamado Victor, que estava com uma furadeira e contou que iria trocar por entorpecentes com André. Adentraram no imóvel e, acompanhados por Erica, irmã de André, localizaram na varanda, dentro de um forno, uma sacola plástica, contendo porções de maconha, um pino de cocaína e R\$ 15,00. Victor confessou que vendia drogas. Apreenderam duas câmeras de vigilância e uma tv. Já haviam abordado diversas pessoas com objetos que falavam que pretendiam levar para a casa de André, conhecido por "Kiko" e trocar por entorpecentes (fls. 04, 05 e 243/244). Como se viu, os policiais, em juízo, acrescentaram que o réu confessou que estava comercializando entorpecentes.

Os relatos dos policiais evidenciam, portanto, que o réu incidiu na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tais depoimentos somente não terá valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

A testemunha arrolada em comum, Jonatan da Silva Oliveira, na delegacia, afirmou que dormia na casa de André, quando os policiais chegaram. Nada de ilícito foi encontrado e não sabia se havia algo ilícito na casa (fl. 08).

A testemunha arrolada em comum, Victor Fernando Silva Araújo, na delegacia, disse que não estava com nada nas mãos e nada sabia sobre os fatos (fl. 07).

Em juízo, as duas testemunhas disseram que estavam na casa de André quando os policiais pularam o muro, adentraram na casa, mandaram o acusado sair e pegaram alguns objetos. Viram quando um dos policiais pegou um saco preto, com drogas, e entregou a outro policial. Na delegacia, os policiais agrediram e ameaçaram Victor para que confirmasse que a droga era de André. Confirmaram, também, que os policiais entraram na casa sem autorização (fls. 243/244).

Como se vê, na delegacia nada relataram sobre terem visto o policial com um saco preto, contendo drogas, nem sobre a agressão ou pressão para delatar o acusado. O depoimento dessas testemunhas, se cotejado com os demais elementos de prova, não podem merecer a mesma credibilidade, vez que ficou demonstrado que agiram com a intenção de afastar a responsabilidade do acusado, lembrando que as testemunhas estavam no local, e uma versão diversa daquela dada por elas poderiam prejudicá-los e até mesmo colocá-los como coautores.

Em síntese, cotejando os depoimentos dos policiais com os das testemunhas, não há como se prevalecer as contraditórias versões dessas duas últimas, mas sim aqueles uniformes trazidos pelos milicianos que participaram da ocorrência, que foi reproduzida por eles com detalhes, em seus depoimentos.

Ademais, não prospera a alegação de que foram pressionados, coagidos e agredidos pelos policiais, já que tal alegação não foi amparada por qualquer prova produzida. Sabe-se que os cidadãos bem intencionados não admitem mais conviver com repressões passadas que foram sepultadas pelo Estado Democrático de Direito instalado em nosso

País na atualidade.

As afirmações das testemunhas acerca da pressão ou agressões feitas pelos policiais são inconsistentes, porquanto, se efetivamente agredidos, insurgiriam-se de pronto e tomariam, logo em seguida, as medidas necessárias para que os policiais fossem punidos, mas nada disso se vê nos autos, pelo contrário, quando ouvidos na delegacia (fls. 250/251 – depoimentos com assinaturas), silenciaram a respeito. Descabida, pois, a alegação de Jonatan e Victor de que Victor teria sido coagido pelos policiais, bem como de que a droga apreendida pelos policiais teria sido, na verdade, plantada por eles para incriminar André.

Por fim, a testemunha arrolada pela defesa, Érika Alves Moreira, irmã do réu, disse que não acompanhou e nem autorizou a busca domiciliar, e que eles retiraram as câmeras de segurança. Não viu as drogas apreendidas e confirmou que seu irmão é usuário (fls. 243/244).

No que se refere aos entorpecentes apreendidos, a perícia apontou que consistem realmente em “maconha” e “cocaína” (exames químico-toxicológicos de fls. 136/138 e 139/141).

De outra parte, a diversidade dos entorpecentes apreendidos; as circunstâncias da abordagem do réu (denúncias de tráfico de drogas no local, realizado pelo réu); a forma de acondicionamento da droga (porções prontas para o comércio); a apreensão de dinheiro (R\$ 15,00); e a ausência de justificativa plausível para a apreensão dos entorpecentes, estão a caracterizar a traficância.

Oportuno frisar que, além dos entorpecentes mencionados, foram apreendidos ainda a quantia de R\$ 15,00 em dinheiro, um televisor, uma furadeira, uma câmera de vídeo, um celular, uma carteira de trabalho, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/17, bens que, de costume, são deixados aos traficantes como garantia do pagamento dos entorpecentes adquiridos pelos usuários.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, o réu foi denunciado guardar e ter em depósito entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a venda a terceiros.

Importante anotar, outrossim, que o simples de fato de a droga não ter sido apreendida em grande quantidade, por si só, não afasta a tipificação do crime de tráfico. Aliás, atualmente, os traficantes vêm utilizando desse modo de agir (distribuição de pequenas porções entre vários entregadores), a fim de dificultar a apreensão da droga e a caracterização do crime de tráfico.

Por fim, anoto que o fato de ter sido absolvido em um processo de roubo, como demonstrado pela defesa às fls. 272/276, em nada influencia nestes autos, porque uma ação não está ligada à outra.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Portanto, a prova coletada nos autos é substancial e convincente, ficando evidente a autoria do crime por parte do acusado, no crime ora apurado. Lembre-se que, no caso, não se exige o chamado “dolo específico”, mas apenas o dolo genérico. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado guardava e tinha em depósito 8,05 gramas de cocaína e 12 (doze) porções pesando 47,62 gramas de maconha, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora o acusado, em seu interrogatório, tenha alegado que é usuário de drogas, tais alegações não restaram comprovadas, até porque a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental. Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem.

Descabida, portanto, a pretendida desclassificação do delito para o do artigo 28 da Lei de Drogas.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito, e passo a aplicar a pena.

O acusado ostenta péssimos antecedentes (fl. 277 - Proc. nº 0000379-48.2018.8.2018.0603, fls. 278/279 - Proc. nº 0012430-35.2009.8.26.0077 e fl. 279 - Proc. nº 001501-34.2008.8.26.0077), razão pela qual uma das circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhe são favoráveis, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima. Portanto, levando em conta o dado elencado, no aspecto acima relatado (péssimos antecedentes), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, elevo a pena em mais 1/3 (um terço) em virtude da agravante da reincidência (fls. 277/278 - Proc. nº 0001346-90.2016.8.2018.0077 e fl. 279 - Proc. nº 0015742-87.2007.8.26.0077), resultando em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa.

Não é caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porque o réu negou a propriedade da droga encontrada, bem como a comercialização. A menoridade relativa também não é reconhecida, uma vez que o réu não era menor de 21 anos, na data do fato.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Neste ponto, não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque, entre os requisitos legais para tal benefício, o acusado deve ser primário e de bons antecedentes, condições que o réu não ostenta.

Torno, pois, definitiva a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia

cautelar, como se verá doravante.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ANDRÉ ALVES MOREIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e pagamento de 888 (oitocentos e oitenta e oito) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 19/11/2020 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugeri-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por

essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade.

Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (destrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem esses argumentos, anoto ainda que a pena fixada ultrapassa quatro anos, além do que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que afasta de

vez a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, incisos II e III, CP).

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 64/65), ocasião em que foram expostos os fundamentos necessários para a custódia cautelar, os quais ficam aqui reiterados, como razão de decidir, bem como aqueles exposto na decisão de fls. 182/183, que indeferiu pedido de liberdade provisória. Ademais, o réu é reincidente em crime doloso e ostenta maus antecedentes, o que enseja a manutenção da prisão cautelar também para a garantia da ordem pública.

A confirmar a necessidade da manutenção da prisão cautelar, estão as decisões proferidas no Habeas Corpus nº. 2275261-55.2020.8.26.0000, impetrado em favor da ora acusada, que teve a liminar indeferida (fl. 93), demonstrando o acerto deste Juízo na segregação cautelar do acusado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada e realizada às fls. 64/65 e 188, nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Como restou provada a procedência ilícita do dinheiro apreendido às fls. 15/17 (R\$ 15,00), não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecente, razão pela qual, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido às fls. 15/17.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado (dinheiro), instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Apesar de serem produtos do tráfico de drogas praticado pelo acusado, diante da natureza dos objetos apreendidos à fl. 15/17 (01 televisor de marca LG 32 polegadas, 01 furadeira elétrica de marca Makita, 02 câmeras de vídeo-informática, 01 telefone celular de marca Xiaomi de cor branca, 01 carteira de trabalho em nome de André Luis Faria), entendo não ser caso de perda em favor do Senad, mas sim destruição imediata quanto à CTPS, independentemente do trânsito em julgado da presente, a qual fica desde já determinada, e de perda dos demais bens, mas sem entrega ao SENAD, mas sim futura e oportuna doação beneficente, após o trânsito em julgado.

Expeça-se o necessário e comunique-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Após o trânsito em julgado, oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento do dinheiro (R\$ 15,00), e sobre a perda e futura doação dos demais objetos, instruindo-se o ofício com as cópias.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 07 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA